

制中，中外合资经营企业的正常运行和管理不仅要受到我国基本法律《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等基础规范的制约，还要受到《中华人民共和国外商投资法》（以下简称《外商投资法》）等特别法律规范的限制。关于中外合资经营企业的法律适用，尤其是同2023年《公司法》的衔接，需要进一步探讨。本案即涉及中外合资经营公司股东会与董事会权限分配的法律问题。尤其是在《外商投资法》规定了五年过渡期后，如何在审判中准确把握中外合资企业的最高权力机构的相关认定标准，是本案中值得研究探讨的重点问题。

2020年1月1日，《外商投资法》施行，原《中华人民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国外资企业法》《中华人民共和国中外合作经营企业法》同时废止。《外商投资法》取消了原《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第三十条规定的“董事会是合营企业的最高权力机构”的规定。依据《外商投资法》第三十一条，中外合资企业的组织形式、组织机构及其活动准则适用《公司法》的相关规定。在2020年1月1日前设立的外商投资企业，在《外商投资法》施行后五年内可以保留原企业组织形式。2023年《公司法》第五十八条和第五十九条又分别列明了股东会是公司的权力机构，且明确对应职权。2020年1月1日至2025年1月1日可以看作是为保障外资企业平稳过渡而设置的过渡期，然而过渡期内企业的最高权力机构是股东会还是董事会在实践中存在较大的争议。

根据《外商投资法实施条例》第四十四条规定，外商投资法施行前依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》设立的外商投资企业，在外商投资法施行后五年内，可以依照《公司法》等法律的规定调整其组织形式、组织机构等，并依法办理变更登记，也可以继续保留原企业组织形式、组织机构等。因此，在《外商投资法》实施后的五年内（2025年1月1日前），依据原《中华人民共和国中外合资经营企业法》设立的有限责任公司，仍可以保持最高权力机构为董事会。中外合资经营企业可以根据企业自身发展，在五年期限内选择合适的时间点，依照《公司法》逐步调整企业的组织形式和架构。如现有外商

投资企业要在规定时间内依照《公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律的规定调整企业组织形式、组织机构等，需要遵循原企业合营合同约定或企业章程规定作出符合相应法律规定的决议，如修订公司章程等。若直接依据《外商投资法》《公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律的规定，由相应的企业机关在违反原有合营合同、企业章程的情况下直接作出决议，可能会导致股东会决议不成立。因此，笔者认为，五年过渡期设置的目的即为给予现有外商投资企业调整其组织结构一定的缓冲期，其在完成组织架构调整之前，仍应适用原有公司章程的规定，由原最高权力机构董事会依法作出决议，完成过渡期内的企业组织形式、组织机构调整。

本案中，某技术公司在新法施行后，未进行组织形式、组织结构的调整，故某技术公司董事会仍是最高权力机构。某技术公司章程也规定董事会是最高权力机构，对于企业增资、减资、合并、分立等特殊事项均由董事会作出决议。因此对于除名股东，董事会当然有权作出决议。除名决议系由董事会作出并非认定涉案决议无效的理由。

编写人：北京市第一中级人民法院 黄旭宁 赵怡博

七、损害公司利益责任纠纷

34

董事、高级管理人员竞业禁止义务中“商业机会”的认定

—— 甲咨询公司诉田某等损害公司利益责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终4645号民事判决书

2. 案由：损害公司利益责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 甲咨询公司

被告(被上诉人): 田某、庄某、某科技公司

【基本案情】

甲咨询公司系某软件公司持股39%的股东，田某系某软件公司的法定代表人、总经理、执行董事，庄某系某软件公司的监事。田某、庄某共同设立了某科技公司，某软件公司与某科技公司在工商登记的经营范围并不一致。甲咨询公司认为田某、庄某利用职务便利谋取了属于某软件公司的商业机会，通过控制某科技公司经营与某软件公司同类的业务，因某软件公司证照、公章等由田某、庄某持有，故甲咨询公司以股东资格向无锡市新吴区人民法院提起诉讼，

要求：(1)判令某科技公司、田某、庄某停止使用某软件公司的商业机会经营业务；(2)判令某科技公司、田某、庄某违反竞业禁止义务所得的收入人民币500万元(暂定，具体金额待司法审计后明确)归某软件公司所有；(3)判令某科技公司、田某、庄某赔偿某软件公司经济损失人民币100万元(暂定，具体金额待司法审计后明确)。

诉讼中，甲咨询公司提供了某软件公司用以在市场上寻找潜在客户的工作方法以及以此获取的潜在客户名单，该名单中有十名客户与某科技公司现在的客户存在重合。某科技公司则在法庭上公开演示了通过关键词可以在公开的软件检索获取潜在客户名字，其通过该方法不仅获取了诉争的十名客户还有其他客户。田某、庄某还举证证明了某软件公司在2019年实际已经停止运营。

【案件焦点】

田某、庄某是否谋取了独属于某软件公司的商业机会，用于自营或他人经营。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市新吴区人民法院经审理认为：甲咨询公司主张其以独特的工作方法在市场上获取潜在客户并建立销售关系，其客户名录中有十家客户被田某、庄某利用其控制的某科技公司抢占，但本案中甲咨询公司并未举证证明该十家客户系某软件公司的商业机会，反而某科技公司举证证明了通过公开的网络搜索途径获得案涉十家客户的过程，该途径系公开、便利的，搜索方式是大众可以获知的，不存在某软件公司独享或属于某软件公司商业秘密的情形；同时，某科技公司亦举证证明了其通过网络搜索除上述十家客户外，亦成功取得了其他多家客户的报备及授权，进一步说明客户的搜索、获得途径系根据软件特性和使用场景公开可得，不存在商业机会。

江苏省无锡市新吴区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第一百四十八、第一百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定， 判决如下：

驳回甲咨询公司的诉讼请求。

甲咨询公司不服一审判决，提起上诉。江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：甲咨询公司认为田某、庄某利用在甲咨询公司任职期间获取的特有的工作技能、工作方法或经营方式，设立的某科技公司并运用，抢占了某软件公司的客户，但其主张的软件销售工作技能、工作方法或经营方式，是该行业早在某软件公司设立之前已有的普遍做法，甲咨询公司亦未能举证该工作技能、工作方法或经营方式系某软件公司运用自身物质条件开发并独创，故前述软件销售工作技能、工作方法或经营方式不属于某软件公司的商业机会。一审中某科技公司具体展示了根据软件使用场景和产品特性，通过公开渠道检索获得可能使用案涉软件的客户的具体过程，报备的客户均系某科技公司公开独立检索获得，该途径系公开、便利，搜索方式是大众可以获知的，不存在某软件公司独享或属于某软件公司商业秘密的情形，同时上述公开检索途径本身也说明十家客户名单不属于商业机会。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、公司法董事、高级管理人员的竞业禁止义务

要厘清公司的董事、高级管理人员是否违反了竞业禁止义务，首先要认定董事、高级管理人员与股东之间竞业禁止的具体范围。竞业禁止通常分为法定竞业禁止和约定竞业禁止。法定的竞业禁止，主要见于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国个人独资企业法》等法律法规对于公司的董事、高级管理人员及企业合伙人、管理人的规定。本案所涉纠纷发生于2020年左右，法院在裁判时适用的是2018年《中华人民共和国公司法》，关于有限公司董事、高级管理人员的竞业禁止义务，主要体现在第一百四十八条第一款规定中，该条规定：“董事、高级管理人员不得有下列行为……（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋

取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务……董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。”2023年《中华人民共和国公司法》修订时，其第一百八十三条对董事、高级管理人员的竞业禁止义务作了进一步的细化规定：“董事、监事、高级管理人员，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但是，有下列情形之一的除外：（一）向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过；（二）根据法律、行政法规或者公司章程的规定，公司不能利用该商业机会。”第一百八十四条规定：“董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。”除前述规定的竞业禁止义务之外，公司还可以与董事、高级管理人员在劳动合同或保密协议中对于竞业禁止义务作细化或者补充约定。公司的董事、高级管理人员应当同时履行法定竞业禁止义务及与公司约定竞业禁止义务。

本案中，田某、庄某作为公司的董事、高级管理人员的一员，没有与公司就竞业禁止达成特别约定，故其竞业禁止义务应以2018年《中华人民共和国公司法》第一百四十八条第一款第五项规定的范围为限。

二、竞业禁止义务的核心问题——商业机会的认定

本案中，甲咨询公司认为田某、庄某利用职务便利，谋取了属于某软件公司的商业机会，并通过另行设立软件科技公司的方式，攫取了本应属于某软件公司的利润。但首先，从两公司工商登记来看，两者的经营范围并不一致。其次，某软件公司提供的证据不足以证明某科技公司运用了独属于某软件公司的商业机会。在认定董事、高级管理人员是否违反竞业禁止义务时，难点在于如何认定商业机会。所谓商业机会，是赢得客户、获取商业利润的机会。对于什么是属于公司的商业机会，笔者认为可从以下几点来考量：（1）该商业机会是公司利用其独有的工作方法或工作平台挖掘；（2）公司符合潜在客户的合作要求，有能力与潜在客户形成商业合作；（3）公司对该商业机会有期待利益，没有拒绝或放弃。

具体到本案中，首先，某软件公司所称的其发掘潜在客户的方法，并非其独创的方法，而是在全行业中比较流行的一种普遍性做法。某科技公司在庭审中对于其获取客户的方法在公开的搜索引擎上进行了演示，搜索引擎是普通民众皆可以接触的工作平台，搜索的关键词也是行业术语，所以某软件公司不能证明田某、庄某系运用了某软件公司特有的工作方法或者工作平台，寻找到的潜在客户。其次，某软件公司虽然提供了自身潜在客户的名单，但并未提供证据证明其与潜在客户欲达成何种形式的合作，该合作形式是否与本案中软件科技公司与客户建立的合作一致，其是否符合潜在客户对于该类合作的对象要求且有能力与潜在客户达成商业合作。最后，通过田某、庄某的举证，某软件公司实际在2019年已经无法运营，即使其拥有潜在客户名单，实际上已无法与潜在客户达成商业合作，即其对其所称的商业机会不具备期待利益。综上，一、二审法院对于甲咨询公司主张田某、庄某利用职务便利获取某软件公司的商业机会用于软件科技公司损害某软件公司利益要求田某、庄某及软件科技公司赔偿的诉讼请求，均未予支持。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 费益君 尹慧 胡伟

公司高级管理人员擅自将工程发包给无资质的承包人 导致公司重大损失，属未尽勤勉义务，应依过错担责

—— 某置业公司诉包甲损害公司利益责任案